

1500278-10.2022.8.26.0598

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ana Virginia Mendes Veloso Cardoso

Comarca: Jaú

Foro: Foro de Jaú

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/10/2022

... conhecido dos meios policiais pelo tráfico e admitiu que as drogas se destinavam à venda. Como se vê, a confissão extrajudicial do réu confirmada pelo relato do policial militar, que o abordou na posse de 10 pedras de "crack" e dinheiro. O réu, já conhecido por tráfico, estava saindo da residência na posse dos entorpecentes, que estavam embalados em porções individuais. Em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jaú

Foro de Jaú - 2ª Vara Criminal

Praça Dr. Mário Gomes Pahin, s/n, Centro, Jaú - SP - cep 17210-100

https://tjsp-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/caiot_tjsp_jus_br/ETLAHwuQfJ9KoGndFQVmbcsB74QhYfYIPbdUN24Vr_9r8A?e=qHMi2l

https://tjsp-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/caiot_tjsp_jus_br/EdHpISx3uLZMsN4PAJ_1icsB2M_B_2a3Q1_qApbq4agu2A?e=PAp32p

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1500278-10.2022.8.26.0598 - Controle 2022/000884

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2164445/2022 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 25607759 - CENTRAL

POL.JUD-JAÚ, 2164445 - DEL.POL.ITAPUI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSÉ HENRIQUE APARECIDO SABINO

Em 24 de outubro de 2022, no horário designado, foi realizada audiência virtual, conforme disciplina estabelecida pela E. Corregedoria Geral da Justiça. Presente a MM Juíza de Direito, Dra. Ana Virgínia Mendes Veloso Cardoso, comigo, Escrevente, teve início a audiência para hoje designada no processo em questão, a qual foi realizada por meio de gravação na plataforma Microsoft Teams e anexada ao termo de audiência, conforme comunicado 1350/2020. Apregoadas as partes, constatou-se ter comparecido o Dr. Wellington Roger Neves, DD. Promotor de Justiça; a Dra. Tatiana Mendes Soares Bachega, Defensora Pública, ora defendendo o acusado JOSÉ HENRIQUE APARECIDO SABINO; e a testemunha Mateus Cardoso da Costa, que prestou seu depoimento. As Partes desistem da oitiva Douglas Henrique Marques, o que foi homologado pela MM Juíza. Ausente o acusado que, apesar de regularmente intimado, não compareceu injustificadamente. A MMª Juíza decretou a sua revelia, após este escrevente verificar no sistema SIVEC de que ele não se encontra preso. Encerrada a instrução, em alegações finais, as Partes debateram oralmente, conforme gravação que segue. Em seguida, seguiu-se deliberação da MM. Juíza: "VISTOS. JOSÉ HENRIQUE APARECIDO SABINO foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06. O acusado foi notificado e apresentou defesa prévia. A denúncia foi recebida em 06 de setembro de 2022. (p. 168-169) e o réu foi citado (p. 200). Durante a instrução foi ouvida uma testemunha. Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do réu. A Defensora requereu a

desclassificação para o artigo 28 da Lei 11.343/06 e, subsidiariamente, a aplicação das benesses legais. É O RELATÓRIO. DECIDO. A ação é procedente. A materialidade do delito restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, fotografias, laudo de exame-químico toxicológico e pela prova oral. Em seu interrogatório na fase inquisitiva, o réu admitiu a prática delitiva (pg. 12). O PM Mateus relatou em juízo a abordagem do acusado na posse de 10 pedras de "crack" e de R\$ 30,00. Narrou que o réu estava saindo da residência e, quando avistou a viatura, tentou colocar no bolso o objeto que tinha nas mãos e retornar para o imóvel, mas foi abordado na calçada. Ele era conhecido dos meios policiais pelo tráfico e admitiu que as drogas se destinavam à venda. Como se vê, a confissão extrajudicial do réu confirmada pelo relato do policial militar, que o abordou na posse de 10 pedras de "crack" e dinheiro. O réu, já conhecido por tráfico, estava saindo da residência na posse dos entorpecentes, que estavam embalados em porções individuais. Em adição, o policial contou que o acusado admitiu o tráfico ilícito no momento da abordagem, conduta que se repetiu perante a D. Autoridade Policial. Nada foi alegado capaz de afastar a credibilidade dos agentes da lei. A propósito: Convém lembrar que os atos administrativos são dotados da presunção de veracidade e legalidade e, não havendo qualquer indício que possa macular esta qualidade, não é de se admitir, por simples contrariedade do sentenciado, que os depoimentos dos agentes públicos estejam eivados de ilegalidade, por um espírito emulativo ou qualquer outra causa espúria. Saliente-se que os depoimentos dos policiais valem como prova, inexistindo razão para desmerecê-los, pois, na condição de servidores públicos, no exercício de suas funções, gozam de presunção juris tantum de que agem corretamente, sobretudo quando suas afirmações são compatíveis com o conjunto probatório. Além disso, 'A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita' (STF, RTJ 68/54). (Apelação nº 0004050-23.2013.8.26.0161 - 4ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo - Relator Willian Campos - julgado em 27 de maio de 2014 - votação unânime). E o fato de o réu não ter sido surpreendido no exato momento da comercialização do entorpecente não afasta a incidência do artigo 33 da Lei 11.343/06, que elenca diversas condutas que se enquadram na prática delituosa prevista no tipo penal. A esse respeito: "TÓXICOS - TRÁFICO - Consumação - Prática de algum ato de tráfico ou "traditio" - Inexigibilidade - Trazer consigo, transportar, ter em depósito ou guardar a substância entorpecente - Suficiência"(...)" (TJSP - Ap. Criminal nº 1.007.360-3/6 - São José dos Campos - 6ª Câmara Criminal - Relator Marco Antonio - J. 17.05.2007 - v.u). Voto nº 5.767. "TÓXICOS - Tráfico - Caracterização - Inexistência de dúvida de que a droga apreendida com o acusado e com co-réu se destinava ao consumo de terceiros, levando-se em conta o grande volume e a forma de acondicionamento, embalada separadamente e pronta para a venda, indicando potencial destinação ao mercado nefasto - Desnecessária a prova de ato de comércio, bastando que o agente traga consigo ou mantenha em depósito a droga para essa destinação, ainda que futura, na medida em que a consumação não exige qualquer resultado (...)"(TJSP - Ap. Criminal nº 1.104.091-3/5 - Sorocaba - 5ª Câmara Criminal - Relator Pinheiro Franco - J. 20.09.2007 - v.u). Voto nº 9.739. Nesse contexto, não há como acolher as teses defensivas, pois restou suficientemente comprovada a prática, pelo acusado, do crime narrado da denúncia. Procedente a ação penal, passo a dosar a pena. Na primeira fase, observo que a pena-base deve ser majorada, considerando a alta potencialidade lesiva do entorpecente apreendido ("crack"), substância altamente nociva e viciante. Assim, fixo a pena-base acima do mínimo legal em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa. Presente a atenuante da confissão, torno a pena ao mínimo legal de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa. Por fim, aplicável o disposto no §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, pelo que diminuo a pena do crime em 2/3, tornando-a definitivamente em 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa. Considerando a primariedade do réu, fixo, excepcionalmente, apesar do disposto no artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei 8.072/90, o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena. É incabível o estabelecimento de regime mais favorável ou a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, até pelo disposto na lei mencionada, que exige tratamento mais rigoroso para o delito aqui

tratado, além dos motivos esposados na primeira fase. O crime de tráfico de drogas, além de ser equiparado a hediondo e ser a principal causa de inúmeros outros delitos, notadamente patrimoniais, gera efeitos nefastos para a sociedade e para as famílias de bem, de modo que a concessão dos benefícios mencionados, além de ser incompatível com a sua gravidade, não se mostraria suficiente para a prevenção ou reprovação do delito (CP, art. 59, *in fine*), gerando ofensa ao disposto no artigo 44, III, CP. Por fim, a despeito das alterações promovidas pela Lei 12.736/12 no art. 387, do Código de Processo Penal, especialmente a inclusão da regra trazida no § 2º deste último dispositivo (o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade), deixo de aplicar de forma antecipada a detração penal por entender que esta lei modificadora é materialmente inconstitucional, afrontando os princípios da individualização da pena, do juiz natural e da isonomia (art. 5º, da Constituição Federal). A propósito, cabe trazer a lume os ensinamentos do Prof. César Dário Mariano da Silva em recente artigo publicado na revista eletrônica Consultor Jurídico: "O princípio da individualização da pena está previsto no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, e dispõe que caberá à lei regular a individualização da pena. A individualização da pena desenvolve-se em três etapas: a legislativa, a judicial e a executória. (...) A nova lei fundiu em uma etapa a judiciária e a de execução das penas, uma vez que, ao proferir sentença, poderá o Juiz promover de regime o condenado sem atentar para a análise do seu mérito, de acordo com o previsto no artigo 112 da Lei de Execuções Penais, que dispõe: "A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão". Com efeito, a Lei das Execuções Penais, que é especial, contém normas que devem ser observadas para a correta individualização da pena. O condenado deverá cumprir a pena privativa de liberdade em etapas cada vez menos rigorosas até obter a liberdade, devendo, para tanto, ser observado seu mérito. Sem essa análise do merecimento para a progressão de regime, inclusive com a realização do exame criminológico quando necessário, está sendo violado o disposto no artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal, que dispõe sobre a individualização da pena. A Lei a ser observada por ocasião da progressão de regime é a das Execuções Penais, que é especial e traz os requisitos necessários, que devem ser analisados pelo Juiz Natural da causa, que é o das Execuções Penais e não o prolator da sentença. Destarte, somente com o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 112 da Lei das Execuções Penais é que poderá ser deferida a progressão de regime pelo Juiz das Execuções Criminais, observado o princípio do juiz natural (art. 5º, LIII, CF), a teor do disposto no artigo 66, inciso III, alínea "b", da Lei das Execuções Penais. E se não bastassem esses argumentos, haverá situações em que pessoas condenadas exatamente às mesmas penas e pelos mesmos crimes terão tratamento totalmente diferente em situações iguais, com evidente violação ao princípio da isonomia. Assim, v.g, aquela

pessoa condenada à pena privativa de liberdade e que tenha sido presa provisoriamente terá abatido o período pelo próprio Juiz da Condenação para fins de progressão, podendo ser diretamente promovida de regime sem a observância do mérito; ao passo que o condenado, que não tenha cumprido prisão provisória, deverá obter a progressão com o preenchimento dos requisitos do artigo 112 da Lei das Execuções Penais a serem analisados pelo Juiz das Execuções Criminais. Há, portanto, dois pesos e duas medidas, ou seja, pessoas sendo tratadas de forma totalmente diferente em situações iguais, violando, assim, o princípio constitucional da isonomia (art. 5º, "caput", da CF)"(<http://www.conjur.com.br/2012-dez-10/cesar-dario-lei-tornar-automatica-progressao-regime> - acesso em 17.12.2012, às 00h40min). Ressalte-se: a modificação proposta pelo legislador é capaz de gerar odiosa injustiça, na medida em que os condenados que tenham sido submetidos a custódia cautelar durante o processo (justamente porque a sua liberdade colocava em risco a ordem pública, a ordem

econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal – art. 312, do Código de Processo Penal) seriam beneficiados em detrimento daqueles que puderam responder ao processo em liberdade, provavelmente indivíduos menos perigosos para a sociedade. E não é só. A antecipação da detração penal acarreta a supressão, no caso de réus presos cautelarmente, das regras para progressão de regime de cumprimento de pena privativa de liberdade, o que também se reflete em insustentável atentado ao princípio da isonomia. Tudo isso sem considerar a possibilidade de que o réu esteja preso em razão de prisão preventiva decretada em vários processos, quando a aplicação irrestrita do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal poderá acarretar a consideração do mesmo período de prisão cautelar para fins de detração em várias sentenças condenatórias, o que não se pode admitir. Assim sendo, por entender que o art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal viola a disciplina constitucional, deixo de aplicá-lo, o que faço com arrimo no controle de constitucionalidade difuso. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia para o fim de CONDENAR o réu JOSÉ HENRIQUE APARECIDO SABINO, qualificado nos autos, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 166 dias-multa, no mínimo legal, pela prática do crime previsto no artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06. Faculto o apelo em liberdade. Custas na forma da lei. Oportunamente, expeça-se o necessário e arquive-se. Publicada em audiência, saem intimados os participantes." NADA MAIS. A sentença foi exibida às partes para ciência. O Ministério Público informou que não deseja recorrer. A Defensora informou que deseja recorrer. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, _____(Caio C. T. Mazziero), digitei.